

1500712-30.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... identificar por temer represália do tráfico, o qual lhes informou que um indivíduo de prenome Anderson, vulgo "Nenê", que trajava camiseta azul com letras brancas, seria o responsável pela distribuição de drogas e o "recolhe" do dinheiro proveniente do tráfico na Rua Bogotá daquele bairro. Com o escopo de apurar a veracidade da denúncia, os milicianos se deslocaram até o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500712-30.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500712-30.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2114904/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 17583891 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

1212/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2114904 - 02º D.P. PIRACICABA,

1212/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DE JESUS CARMELO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisela Ruffo

Vistos.

ANDERSON DE JESUS CARMELO e CAIQUE JUIZ SOARES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de abril de 2021, por volta das 17h55min, na Rua Bogotá, nº 333, bairro Jardim Esplanada, nesta cidade e comarca de Piracicaba, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios entre si, traziam consigo, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 108 (cento e oito) porções de maconha, pesando cerca de 138g (cento e trinta e oito gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares estavam em regular patrulhamento pelo local dos fatos, quando foram abordados por um transeunte, que não quis se identificar por temer represália do tráfico, o qual lhes informou que um indivíduo de prenome Anderson, vulgo "Nenê", que trajava camiseta azul com letras brancas,

seria o responsável pela distribuição de drogas e o “recolhe” do dinheiro proveniente do tráfico na Rua Bogotá daquele bairro. Com o escopo de apurar a veracidade da denúncia, os milicianos se deslocaram até o local indicado, onde visualizaram CAYQUE e ANDERSON, sendo que as características de vestimenta passadas pelo informante coincidiam com as deste acusado. Ao avistarem a viatura, ambos os réus tentaram se esquivar da abordagem, tendo CAYQUE adentrado em uma oficina de conserto de ferramentas e dispensado uma trouxinha branca contendo 32 porções de maconha, fato este que foi visualizado pelos policiais. ANDERSON, a seu turno, foi abordado defronte ao mesmo estabelecimento comercial e confessou que trazia em sua genitália entorpecentes. Em seguida, os policiais conduziram ANDERSON até a viatura e, após busca pessoal, apreenderam em sua posse duas trouxinhas contendo 33 porções de maconha cada, 10 porções maiores dessa mesma droga e a quantia de R\$ 125,00 em notas diversas.

Os réus foram notificados nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 242 e 252) e apresentaram defesa preliminar (fls. 255/260 e 270/271), seguindo-se a decisão de fls. 272/274, que recebeu a denúncia em 09.08.2021.

Designada audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e cinco pela Defesa. Após, os réus foram interrogados.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. Observo, de início, que não há que se falar em nulidade do processo em razão de violação do direito dos acusados de permanecer em silêncio, pois, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante prestaram declarações acompanhados de seus respectivos advogados.

2. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal dos acusados.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, pelas fotografias de fls. 52/55 e pelo laudo de fls. 231/233, que trouxe resultado positivo para maconha.

A autoria também restou comprovada.

Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, os réus negaram a prática do crime.

ANDERSON alegou que estava com as porções de maconha porque é usuário de entorpecentes. Asseverou que foi até a “biqueira”, na Rua Bogotá, e pegou R\$ 100,00 em maconha. Aduziu que foi até a oficina para buscar seu carro, mas ele não estava pronto, e estava na calçada quando foi abordado pelos policiais militares, que o revistaram e acharam as drogas destinadas ao seu uso. Aduziu que conhecia CAYQUE de vista. Disse que, por ocasião da abordagem, estava na oficina e CAYQUE só estava passando pelo local. Asseverou que não gostava de usar maconha dentro de casa por respeito aos filhos e à mulher. Disse que trazia consigo também um celular e R\$ 486,00 em dinheiro, que não foram apresentados pelos policiais na delegacia de polícia. Alegou que trabalhava fazendo carreto, pagava aluguel e tinha filhos pequenos, que dependiam do seu trabalho (fls. 07/08).

CAYQUE, a seu turno, disse que as drogas apreendidas em seu poder não lhe pertenciam. Afirmou que estava na tabacaria, quando sua namorada chegou de Uber e foi levá-la até a casa da avó, que ficava na esquina, a 50 metros do local. Quando estava voltando, foi abordado pelos policiais militares e levado para a lateral da tabacaria, onde ele e Anderson foram informados de que seriam presos. Asseverou que não conhecia o corréu Anderson. Disse que foi preso quando estava passando defronte a uma oficina. Asseverou que não chegou a entrar nesse estabelecimento. Aduziu que não confessou a posse de drogas aos policiais, que, inclusive, deixaram de declarar seus direitos constitucionais, tendo o policial Colasan, na ocasião, dito ainda: “Cadê seu padrasto, que é advogado? Quero ver se vou ser educado com ele”. Disse que já foi abordado três vezes pelo policial militar Colasan e que recebeu uma ligação dele, exigindo informações sobre o tráfico, caso contrário, “seria a bola da vez e iria prendê-lo”. Asseverou que também já foi abordado outras vezes pelos policiais da Força Tática, na tabacaria, e, na última oportunidade, seu padrasto, que é advogado, compareceu no local e o PM Colasan acabou discutindo com ele.

Aduziu que não ofereceu resistência à ordem de prisão. Disse que o seu padrasto, Dr. Wesley, tinha imagens do local, que foram apresentadas à Autoridade Policial, comprovando a inexistência de resistência à prisão, porém, como essas imagens não foram apresentadas em mídias, e não foi possível a apreensão e juntada aos autos, ficando o seu advogado responsável por apresentá-las em juízo. Asseverou que possui imagens de vídeo que comprovam que, às 17h32, estava dentro da tabacaria. Disse que já foi preso e declarado usuário de maconha.

Em juízo, voltaram a negar a prática do crime, reiterando, em linhas gerais, suas versões.

ANDERSON afirmou que, no dia dos fatos, foi buscar seu carro na oficina, na Rua Bogotá, mas o veículo não estava pronto, razão pela qual foi até a biqueira e comprou R\$ 100,00 de maconha, posto que é usuário. Asseverou que o proprietário da oficina, Gustavo, o chamou para conversar e depois entrou no estabelecimento para lavar as mãos. Disse que ficou na calçada, mexendo no celular, e, do nada, Cayque, que estava passando, foi abordado pelos policiais, que também o abordaram. Admitiu que eles encontraram dez porções de maconha em seu poder e pegaram seu telefone. Após, os policiais entraram e saíram da oficina. Então, os policiais disseram que ele estava preso e o colocaram na viatura. Disse que conhecia Cayque de vista e nunca tinha conversado com ele. Afirmou que os policiais não encontraram drogas com Cayque, nem na oficina, onde entraram para ver se eles tinham jogado alguma coisa. Aduziu que usa maconha desde os 25 anos e, de vez em quando, cocaína. Acrescentou que tinha saído com R\$ 600,00, comprou R\$ 100,00 de maconha, tubaina, e pagou o Uber, restando-lhe R\$ 486,00 em seu poder, mas os policiais só apresentaram R\$ 125,00.

CAYQUE afirmou que, no dia dos fatos, estava esperando sua namorada chegar na Tabacaria, local onde ela trabalhava. Disse, quando ela chegou com o Uber, pagou o motorista e foi com ela até a casa da avó dela, que fica na esquina. Asseverou que a deixou na frente da casa, onde ela para deixar a bolsa, e retornava para a tabacaria quando Anderson, que estava na mesma calçada que ele, um pouco mais à frente, foi abordado pelos policiais. Alegou que, quando foi passar pela abordagem para entrar na adega, os policiais o chamaram e o abordaram também. Atestou os policiais os revistaram e os levaram para um terreno baldio, que fica ao lado. Afirmou que eles começaram a conversar com Anderson, pedindo a chave do carro do Anderson. Declarou que abriram o porta-malas e os colocaram ali, dizendo que estavam presos. Sustentou que, na Delegacia, um policial retirou uma sacola verde da bolsa dele e apresentou na delegacia. Depois, constatou que colocaram 32 parangas de maconha nele e o acusaram de estar vendendo drogas, mas não tinha nada em seu poder. Disse que não viu nada com Anderson na hora da abordagem. Atestou que não entrou nem tentou entrar em nenhuma oficina. Aduziu que não conhecia Anderson anteriormente. Acrescentou que já conhecia os policiais, mas nada tinha contra eles. Disse que já tinha sofrido abordagem anterior deles, num dia em que o pegaram fumando maconha num churrasco. Alegou que os policiais disseram que ele era bandido, por já ter passagem, e queriam que ele desse o traficante do bairro dar o traficante do bairro, mas falou que só a namorada dele morava no bairro e os policiais o liberaram. Afirmou que, no mesmo dia, passaram em frente à casa de sua namorada e falaram algo de dentro da viatura. A partir desse dia, sempre que o viam, queriam abordá-lo, dizendo que ele estava devendo e tinha que dar algum traficante para eles. Aduziu que, certo dia, foi abordado na Rua Bogotá, para onde seu padrasto se dirigiu e se identificou como advogado, mas os policiais não gostaram e ofenderam tanto seu padrasto como sua mãe. Declarou que os policiais deixaram bem frisado que o liberariam mas ainda iriam prendê-lo então, depois de três semanas, acabou sendo preso. Disse que conhece o bairro Esplanada e a Rua Bogotá, onde mora a avó da sua ex-namorada e fica a tabacaria onde ela trabalhava, mas não sabe dizer se há biqueiras no local. Acrescentou que há filmagens que demonstram que ele estava na tabacaria aguardando sua então namorada pouco tempo antes de eu ser abordado.

A prova dos autos, porém, é maciça e incriminadora.

Com efeito, o policial militar Ranieri relatou que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento e receberam denúncia de um cidadão que não quis se identificar, dando

conta de que, na Rua Bogotá, estaria um indivíduo de nome Anderson, vulgo "Nenê", com camisa azul e listras brancas, que seria responsável pela distribuição de drogas no bairro e recolha do dinheiro. Atestou que foram ao local dos fatos, viram um indivíduo com as características informadas, junto com um outro, posteriormente identificado como Cayque. Informou que, quando eles viram a viatura, rapidamente se separaram, tendo Cayque adentrado a uma pequena oficina e Anderson começado a andar disfarçadamente. Asseverou que, quando Cayque adentrou na oficina, soltou uma trouxa pequena, de plástico branco, que foi recolhida posteriormente, constatando-se que continha porções de maconha. Disse que Anderson confessou que estava com drogas em suas vestes. Informou que Cayque foi retirado da oficina, recolheram a trouxa que estava caída e levaram os dois na lateral da loja, pois o proprietário falou que não reconhecia Cayque como seu cliente. Atestou que Anderson foi colocado na viatura e foram retiradas as porções que estavam em suas roupas íntimas, além de R\$ 125,00. Atestou que, ao receber ordem de prisão, Cayque ficou exaltado e relutante, sendo necessário usar um pouco de força física e algemas para contê-lo. Aduziu que Anderson admitiu que a droga encontrada em seu poder se destinava à venda, já Cayque não falou nada. Disse que não se recordava do local onde receberam a denúncia, apenas que ficava nas proximidades do bairro onde foi feita a abordagem, nem quanto tempo se passou do momento em que receberam a denúncia até a abordagem, dado o tempo decorrido, sendo possível que fosse meia hora. Esclareceu que foi ele quem recolheu a sacola dispensada por Cayque, enquanto Colasan abordou Anderson. Disse guardou a sacola na sua farda, para ficar com as mãos desocupadas para continuar a operação policial.

O policial militar William relatou que estavam em patrulhamento e receberam denúncia anônima de que um indivíduo de nome Anderson seria o responsável pela distribuição de drogas na Rua Bogotá e o recolhimento do dinheiro, com camiseta azul com escritos brancos. Atestou que se deslocaram ao local informado e, ao adentrar a vida, avistaram um indivíduo com as características citadas, junto com outro indivíduo. Disse que, ao notarem a viatura, eles se separaram, tendo um deles, identificado como sendo o corréu Cayque, adentrado a uma loja de conserto de ferramentas, enquanto o outro, identificado como sendo Anderson, objeto da denúncia, foi abordado. Esclareceu que Cayque dispensou um kit de 32 porções de maconha. Já o corréu Anderson admitiu, de pronto, que estava na prática do tráfico e que tinha drogas na cueca. Relatou que lhes deram ordem de prisão e Cayque resistiu, sendo necessário o uso de força moderada. Então, na viatura, retirou das vestes de Anderson 3 kits de drogas, dois com 33 porções, mais um com dez, totalizando 7 porções, além de R\$ 125,00. Declarou que, no local dos fatos, o corréu Cayque também lhe falou que estava na prática do tráfico. Afirmou que não se recordava de ter abordado o corréu Cayque anteriormente, nem de o advogado do réu ter acompanhado alguma abordagem anterior. Acrescentou que receberam a denúncia anônima próximo da Rua Bogotá e, depois de aproximadamente 30 minutos, fizeram a abordagem.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais militares não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Cabe anotar, por fim, que, em razão das inúmeras ocorrências atendidas diariamente pelos policiais, é natural que haja pequenas divergências entre seus depoimentos,

sobre circunstâncias secundárias, o que, aliás, confere ainda mais veracidade aos seus depoimentos, posto que, se tivessem qualquer intenção de prejudicar quem quer que fosse, apresentariam declarações idênticas. Logo, não tem a relevância pretendida pela combativa defesa o fato de um dos policiais ter afirmado que o corréu Cayque confessou informalmente a prática do tráfico, enquanto ou outro asseverou que ele nada falou sobre as drogas, até porque é possível que a informação tenha sido mesmo colhida apenas por um dos policiais.

A divergência, aliás, infirma a assertiva de que teria havido quebra da incomunicabilidade das testemunhas, pois, caso tivessem mantido contato, teriam apresentado relatos idênticos.

Anoto, para constar, que, sendo as audiências realizadas de forma online, é comum que haja dificuldades técnicas e de conexão para ingresso no sistema, causando, por vezes, atrasos, e, na hipótese, o depoimento do policial Colasan chegou inclusive a ser suspenso, em razão de problemas de conexão, não sendo possível concluir, como pretendido pela combativa Defesa, que o atraso no ingresso da testemunha tenha ocorrido porque manteve contato com o primeiro policial ouvido.

Pontuo, outrossim, que não desmerece o relato dos policiais o fato de eles não aparecerem portando a sacola que apreenderam na oficina não nos prints que instruíram as alegações finais da Defesa.

Trata-se de imagens extraídas de um vídeo de 25 segundos feito a partir de uma câmera situada no interior de um estabelecimento comercial, que mostra os policiais caminhando na calçada em frente, conduzindo os réus, sendo incapaz, portanto, de revelar toda a diligência. De todo modo, o mesmo vídeo demonstra que uma viatura acompanhava a ação, transitando pela via, e o policial Ranieri esclareceu que, após recolher a droga dispensada, colocou-a na farda para manter as mãos desocupadas enquanto concluía os procedimentos da abordagem.

Pelos mesmos motivos, isto é, porque o vídeo revela apenas a passagem de policiais e réus em frente da loja, em poucos segundos, tampouco se pode dizer que afasta a assertiva dos policiais de que o corréu Cayque teria se mostrado exaltado e relutante ao receber a voz de prisão.

Por fim, anoto que o policial Colasan declarou que se passaram aproximadamente trinta minutos do momento em que receberam a denúncia até o momento da abordagem e o policial Ranieri disse que não se recordava precisamente do tempo, sendo até possível que fosse meia hora.

Cuida-se, portanto, de mera estimativa de tempo feita pelos policiais, não sendo relevante, pois, para o deslinde do feito.

De outro lado, as testemunhas arroladas pela Defesa não inocentam os acusados.

Gustavo atestou que não presenciou o momento da abordagem. Disse que teve contato com Anderson no dia dos fatos, por volta das 17h40 ou 17h45. Atestou que Anderson presta serviços para ele e, no dia dos fatos, passou por ali, razão pela qual o chamou para conversarem, na Rua Bogotá. Disse que conversaram até às 18h. Depois, entrou para lavar a mão, pois era final de expediente, e não presenciou a abordagem, que se deu defronte ao estabelecimento. Afirmou que não viu ninguém entrar no seu estabelecimento, pois estava lavando as mãos no banheiro. Esclareceu que os policiais entraram dizendo que um rapaz entrou na oficina e eles dariam uma olhada, mas não falaram se encontraram alguma coisa no local. Disse que que Anderson presta serviços para ele. Aduziu que Anderson é usuário de maconha. Acrescentou que, não região, há bastantes pontos de drogas, mas na frente do seu estabelecimento não.

Viviane, mãe do corréu Cayque, também não presenciou o momento da abordagem. Disse que, no dia dos fatos, ele saiu de casa por volta das 16h30 ou 17h, para se encontrar com Naomi, sua namorada, na tabacaria, onde ela trabalhava. Disse que ele não estava trabalhando e não tinha renda à época dos fatos, é usuário de maconha, mas nunca foi internado. Atestou que, no dia 03 de abril, três semanas antes de ele ser preso, o réu tinha saído para buscar a namorada e para ir ao supermercado. Após, Naomi lhe telefonou e falou que ele tinha sido abordado por policiais.

Atestou que seu marido foi ao local da abordagem e se identificou como advogado, com a carteira da OAB, mas estava sem terno. Alegou que os policiais Colasan e Gama foram grosseiros com seu marido e Colasan falou que ele não poderia acompanhar a

abordagem. Disse que os policiais usaram palavras de baixo calão e Gama a ofendeu, dizendo que ela encobria coisas erradas que Cayque fazia, bem como que, numa próxima abordagem, iriam prender Cayque. Aduziu que, após essa situação, os policiais passaram várias vezes perto da sua casa e, numa ocasião, ainda tentou entrar em sua casa, tanto que acharam melhor mudar de casa.

Naomi, por sua vez, disse que começou a namorar o corréu Cayque em setembro de 2021 e ficaram quatro meses juntos, tendo terminado o relacionamento em janeiro de 2022. Asseverou que, após o término do namoro, continuaram mantendo contato. Aduziu que começou a conversar com ele pela rede social e se encontrou com ele pela primeira vez um mês antes do início do namoro. Afirmou que, no dia dos fatos, estava na sua casa, no Jardim Dona Lourdes, e pediu um Uber para ir até a Tabacaria, onde trabalhava. Asseverou que chegou ao local, encontrou-se com o réu e ele pagou o transporte. Após, foram até a casa da sua avó, que fica bem próxima e entrou para cumprimentar seus avós e deixar sua mochila. Disse que ficou uns dez minutos no local e, quando saiu, o réu já estava sendo levado para a viatura. Alegou que ele não portava drogas. Informou que ligou para a mãe e para o padrasto de Caíque. Atestou que os fatos se passaram no dia 27, em janeiro de 2021, e se confundiu quanto às datas, já que começou a namorar o réu em setembro de 2020 e ficou com ele até janeiro de 2021. Acrescentou que o réu já tinha sido acordado outras vezes, inclusive quando fizeram um churrasco e ele estava fumando maconha. Declarou que os policiais ficaram pressionando Cayque para dizer de quem tinha comprado e ele ficou com medo. Asseverou que, uma vez, estavam juntos, passando perto do mercado, e os policiais o levaram para o outro lado da rua. Disse que ligou para a mãe e para o padrasto dele, que compareceram no local e foram ofendidos pelos policiais. Sustentou que isso aconteceu no dia 03 de janeiro, antes de ele ser preso.

Seu depoimento, porém, deve ser recebido com a máxima reserva. Com efeito, há inúmeras contradições em seu relato, não tendo Naomi sequer logrado precisar quando se deram os fatos, tendo afirmado que namorou o réu, durante quatro meses, de setembro de 2020 a janeiro de 2021, e que os fatos ocorreram no dia 27 de janeiro de 2021, quando, na realidade, ocorreram no dia 27 de abril.

Enfim, o fato de os policiais terem recebido denúncia dando conta traficância no local, e, logo em seguida, terem visualizado ANDERSON, cujas características físicas e de vestimentas, bem como o apelido coincidiam com os informados pelo denunciante, e CAYQUE, juntos no local indicado, os quais saíram correndo ao notar a aproximação da viatura, vindo a apreender uma trouxinha de cor branca, contendo 32 porções de maconha, que CAYQUE dispensou no chão durante a tentativa de fuga, e duas trouxinhas contendo 33 porções de maconha cada uma, uma outra trouxinha com 10 porções um pouco maiores da mesma droga, na posse de ANDERSON, o que não foi infirmado por nenhum elemento seguro de prova, conduz à certeza quanto à autoria, sendo mesmo desnecessária a conversão do julgamento em diligência para vinda aos autos do relatório de movimentação da viatura policial no dia 03 de abril de 2021. Prosseguindo, a quantidade de entorpecentes apreendidas, e a forma como estavam acondicionados, aliados à existência de denúncia previa dando conta da traficância, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.” (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido.” (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j.

26/04/2012, v.u.).

Não é demais anotar que o fato de os acusados serem usuários de entorpecentes, não implica, por si só, na desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498). Impõe-se, portanto, a condenação dos réus, nos termos da denúncia.

O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de conteúdo múltiplo. Descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas.

Na hipótese, as condutas típicas tazer consigo - entorpecente para fins de tráfico, isto é, para venda, distribuição ou entrega ao consumo de terceiros - ficaram configuradas e se subsumem perfeitamente ao tipo penal em comento, sendo irrelevante o fato de que os réus eventualmente não promovessem atos de venda. Bem por isso, não tem a relevância pretendia pela Defesa o fato de o corréu Cayque estar em um estabelecimento comercial pouco tempo antes da abordagem, como atestam as filmagens juntadas aos autos.

3. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, observo que ANDERSON é primário e não ostenta maus antecedentes. CAYQUE, a seu turno, é reincidente (cf. cert. à fls. 222/224). Essa circunstância, porém, será analisada na segunda fase de fixação da pena, evitando-se bis in idem. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor mínimo legal, para ambos.

Na segunda fase de fixação da pena, não há circunstâncias agravantes e, porque fixada a pena no mínimo legal, nenhuma atenuante pode reduzi-la.

É certo que CAYQUE ostenta duas condenações pela prática de porte de entorpecentes para consumo próprio (autos 0005374-46.2016 e 0000852-80.2017, ambos desta 4ª Vara Criminal - fls. 222/224). Porém, essas condenações não podem ser consideradas para majoração da pena ora imposta e caracterizar reincidência, por não ser compatível com o princípio da proporcionalidade do direito penal, porquanto implicaria punição maior do que a aplicada por conta da própria infração anterior.

Nesse sentido já decidiu o E. STJ: "Cabe ressaltar que as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o artigo 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade" (HC 453.437/SP, j. 04/10/2018 Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/10/2018).

"Se a contravenção penal, punível com pena de prisão simples, não configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração, para fins de reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja crime, é punida apenas com "advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo" (Habeas Corpus 478.757/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 11/2/2019). Inexistem causas de aumento.

De outro lado, não há indícios do envolvimento dos réus com o crime organizado, razão pela qual, com relação a ele, reduzo a pena em metade, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, totalizando dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa. Anoto que não é cabível redução maior em razão da quantidade da droga apreendida (138 g de maconha), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

No que tange à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, consigno que, com a edição do Novo Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão do disposto pelo art. 3º do Código de Processo Penal, estabeleceu-se a necessidade de os juízes observarem o precedente ao julgar determinada matéria.

Com efeito, o art. 926 do Código de Processo Civil dispõe: "Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente."

Já o art. 927 do mesmo código estatui: "Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados."

Prosseguindo, o art. 928 estabelece: "Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos".

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.118.533/MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda.

Nesse contexto, anotou a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do Recurso Especial paradigma 1.329.088/RS, referente ao Tema 600 do Superior Tribunal de Justiça: "É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalícia, sob o rito dos recursos repetitivos".

E, de forma unânime, decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela interpretação da lei federal e sua correta aplicação, acompanhando o entendimento consolidado pela Corte Suprema, que o tráfico de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06) não é crime equiparado a hediondo, cancelando a súmula 512, editada em 2014 após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos repetitivos.

Enfim, estando pacificada nas Cortes Superiores a não hediondez do tráfico privilegiado, sendo o réu primário e imposta pena inferior a quatro anos, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Por fim, comprovada a origem ilícita do dinheiro apreendido, declaro seu perdimento.

4. Pelo exposto, JULGO PPROCESSO o pedido, para condenar ANDERSON DE JESUS CARMELO e CAYQUE JUIZ SOARES, qualificados nos autos, à pena de dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial aberto, como incurso no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Declaro perdido o dinheiro apreendido.

Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Piracicaba, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA